

1500010-71.2020.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Damariane e Maria Tercina quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, e absolver os acusados quanto ao delito de associação para o tráfico, ante a ausência de provas.

- Art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (rés Damariane e Maria Tercina)

A existência material ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1500010-71.2020.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500010-71.2020.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de DAMARIANE TOMAZ DE PAULA (qualificada a fl. 23), MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA (qualificada a fl. 24), IRAN FERNANDES RAMOS (qualificado a fl. 119) e DANIEL CEZAR ROCHA (qualificado a fl. 128), imputando-lhes as condutas: a) DAMARIANE TOMAZ DE PAULA e MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA como incursoas no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006; b) DAMARIANE TOMAZ DE PAULA, MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA, IRAN FERNANDES RAMOS e DANIEL CEZAR ROCHA como incursoas no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, sob a alegação de que, em tese, no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 8h30min, na Penitenciária Sargento PM Antônio Luiz de Souza, localizada no município de Reginópolis, nesta comarca, as denunciadas Damariane e Maria Tercina, em identidade de propósitos, traziam consigo droga, para entregar a Iran Fernandes e Daniel Cezar, consistente em 80,91g (oitenta gramas e noventa e um centigramas) de Cannabis sativa. Em data incerta de 2019, no interior do referido estabelecimento penal, em um dia de visitaç o, os quatro denunciados se associaram para introduzir droga naquela unidade prisional, visto que Daniel explanou o esquema de entrar com droga na comida.

Segundo a denúncia (fls. 150/154): "Ao que se apurou, Iran Fernandes Ramos e Daniel Cezar Rocha cumprem pena privativa de liberdade na PII de Reginópolis. Damariane Tomaz de Paula é esposa de Iran e consta no seu rol de visitas. Maria Tercina da Silva Nogueira é avó de Daniel e figura na sua relação de visitante. Em data incerta de 2019, no interior do referido estabelecimento penal, num dia de visita, os quatros denunciados se associaram para introduzir droga naquela unidade prisional, visto que Daniel explanou o esquema de entrar com droga na comida, pois sabia que os agentes de segurança penitenciária passavam a faca superficialmente no recipiente e a droga ficaria no fundo. Assim, Damariane ficou encarregada de adquirir o pote plástico (tupperware) de tamanho grande, para o instrumento de revista não chegar até o fundo, e entregar o dinheiro (R\$ 150,00 por evento) para Maria Tercina adquirir maconha.

Assim, estando todos previamente ajustados e com unidade de propósitos, em duas datas distintas de 2019, as denunciadas Damariane e Maria Tercina adquiriram maconha e colocaram no fundo do pote plástico e conseguiram passar pela revista do estabelecimento penal, entregando a droga para Iran e Daniel.

Contudo, no dia 12 de janeiro de 2020, quando mais uma vez as denunciadas Damariane e Maria Tercina traziam consigo maconha para entregar a Iran e Daniel, foram flagradas durante o procedimento de revista pelos agentes de segurança penitenciária, que constatarem a referida droga no meio da comida, conforme fotografias de fls. 26/28".

As acusadas Maria Tercina da Silva Nogueira e Damariane Tomaz de Paula foram presas em flagrante (APF de fls. 1/2) e, em sede de audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 77/80), expedindo-se, portanto, o alvará de soltura.

Os acusados foram notificados (Damariane - fls.194; Maria - fls. 215; Iran - fls. 177; Daniel - fls. 175) para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006, assim o fazendo às fls. 186/187 (Iran), fl. 190 (Daniel), fls. 204/209 (Damariane) e fls. 222/225 (Maria).

Afastada a hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida às fls. 226, em 22 de maio de 2020.

A decisão de fls. 237/238 designou audiência de instrução, debates e julgamento. Ainda, na decisão de fls. 629, foi decretada a revelia dos réus Daniel, Damariane e Maria Tercina. Já em fls. 676, a revelia da ré Damariane foi relevada, diante da notícia de sua prisão.

Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, procedeu-se ao interrogatório dos acusados presentes.

Encerrada a instrução, foi deferido prazo para apresentação de alegações finais. O Ministério Público, em memoriais (fls. 706/719) requereu a condenação nos termos da denúncia, diante da suficiência probatória de materialidade e autoria delitivas. A defesa de Iran (fls. 720/721), por seu turno, clamou pela absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. A defesa de Damariane (fls. 722/727) postulou pela absolvição da ré por insuficiência probatória. Nos mesmos termos se encontra a defesa de Maria Tercina (fls. 731/734) e Daniel (fls. 735/738).

É o relatório.

Fundamento.

O feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06 às rés Damariane e Maria Tercina, bem como do artigo 35, caput, cc/ artigo 40, inciso III, da mesma Lei a todos os acusados.

Passo a análise da prova oral produzida.

O agente penitenciário Ernesto Rodolfo Guadalín, testemunha da acusação, em juízo, relatou que na data dos fatos, ao fazerem a revista na alimentação que a ré Maria Tercina trazia para a unidade, depararam-se com um volume envolvido por plástico no

meio dos alimentos. Pela suspeita de ser droga, a ré foi levada à delegacia e o produto foi encaminhado para perícia. Era uma substância verde, parecida com maconha. Conhecia as rés por serem visitantes do presos. Não teve uma apuração preliminar sobre a associação de tráfico. A Maria Tercina apenas indicou que a vasilha não era dela, mas não indicou de quem era. Primeiro, a alimentação e os pertences aos presos são passados pelo Raio-X, e, após, fazem uma revista manual, com garfo e faca, na alimentação. É uma pessoa por vez a ser revista. Nesta oportunidade, apenas a ré Maria Tercina passou pela revista. Após encontrarem o volume dentro da vasilha, a ré Maria passou a dizer que não era dela, que havia tido uma troca anterior da vasilha antes de entrarem na unidade. A ré Maria Tercina indicou que a vasilha era da Damariane. Nunca teve interceptação de ligação entre os réus. Nunca chegaram a presenciar nenhuma reunião entre eles também. Nunca presenciou o réu Iran entregando droga para ninguém na penitenciária. Da mesma forma, nunca presenciou o réu Daniel com drogas na penitenciária. Após encontrarem o material estranho, a ré Maria Tercina foi separada. Após, chegou a vez da ré Damariane, e como já a conheciam, também a retiraram na revista. A Maria Tercina confirmou que era da Damariane e ambas foram levadas até a delegacia.

O agente penitenciário Marcelo Mendonça, testemunha da acusação, em juízo, disse que, neste dia, estava tendo visita dos presos e, como de praxe, as visitas trazem alimentação em vasilhas de plástico. Nesta data, a visitante Maria Tercina passou com a alimentação pelo scanner e após foi para a vistoria. O Ernesto encontrou uma substância verde com cheiro semelhante à maconha. Com isso, foram todas as medidas cabíveis. A princípio, a ré Maria alegou que a sacola não era dela, mas foi indagada, porque todo o procedimento de vistoria é individual e acompanhado pela visitante. Antes, em nenhum momento, mencionou que não era dela a vasilha, apenas após o encontro da substância. Sobre a ré Damariane, recorda-se que também estava na visita e foi encaminhada para delegacia. A ré Maria Tercina quem indicou que a sacola pertencia à corré Damariane. Nunca presenciou nenhuma reunião dos quatro réus. Nunca presenciou o réu Iran passando droga para outro dentro da penitenciária. Deste dia, só presenciou a droga encontrada na alimentação, mas não tem conhecimento da relação com os réus que estava detentos na ocasião.

O réu Daniel Cezar Rocha, em seu interrogatório, disse que os fatos denunciados não são verdadeiros. Já estava na unidade prisional há aproximadamente dois anos e sua avó lhe visitava uma vez por mês, porque não tinham muitas condições. Era "zuado" porque todos da penitenciária sabiam que ele tinha se entregado à polícia, justamente porque pretendia sair do crime para cuidar da sua avó. Como sua avó era de idade, sempre levava comida a mais e conseguia entrar com alimentos que outros visitantes não traziam. Os demais réus começaram a perceber esta facilidade. Conheceu o réu Iran jogando bola. Uma visita antes, o Iran perguntou se sua avó não faria um favor a ele e sua mulher. Explicou que nas visitas de sua esposa, muita coisa era retirada, diferente da marmita do depoente, que sempre estava cheia. O réu Iran pediu para a sua avó, então, entrar com a sua marmita. Instruiu a própria esposa do réu Iran conversar com sua avó, pois caberia a ela fazer ou não este favor. No dia que foi chamado, até chorou, porque não sabia o que estava acontecendo. Atualmente, já passou por dois serviços registrados e está trabalhando com carteira assinada. Não sabia que tinha droga ali. Estava foragido e se entregou; logo, não faria nada para se prejudicar na prisão, muito menos sua avó, que era sua única visita, pois sua mãe é alcoólatra e não lhe visitava. Sua avó foi enganada, como se fosse "laranja", porque sua avó é leiga de tudo, evangélica, boazinha. Sua avó desconhecia o conteúdo da vasilha. Sua avó sempre leva duas vasilhas iguais, com seu nome, porque não sabe ler e nem escrever. Nunca tinha visto a ré Damariane. Sua avó a conheceu na fila.

A ré Damariane Tomaz de Paula, em seu interrogatório, disse que os fatos não são verdadeiros. Estavam na visita e pegaram a Sra. Maria com a droga. Com isso, foi presa porque a corré teria indicado que a droga era sua. A droga não era sua. Já conhecia a corré das visitas. A corré Maria lhe pediu uma vasilha emprestada na entrada do presídio. Emprestou uma vasilha vazia para a corré que estava dentro de seu carro, não sabia da droga. Não teve contato anterior com o réu Iran. A ré Maria

pediu a vasilha e seguiu seu caminho e não a viu mais. Só a viu após ser buscada pelos agentes penitenciários. Negou a propriedade da droga, bem como não viu o entorpecente. Foi levada à delegacia, mas não falou que a propriedade era sua. Não se recorda se assinou algum documento, mas não chegou a ler.

O réu Iran Fernandes, em seu interrogatório, disse que não são verdadeiros os fatos. Não pediu para ninguém para entrar com a droga. Conhecia apenas o Daniel, porque jogavam bola juntos na penitenciária. Não conhecia a avó do Daniel, nunca teve contato.

A ré Maria Tercina da Silva Nogueira não foi ouvida em juízo, com sua revelia decretada.

Eis a prova produzida.

Encerrada a exposição da prova oral convém salientar que a ação penal é parcialmente procedente, a fim de condenar Damariane e Maria Tercina quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, e absolver os acusados quanto ao delito de associação para o tráfico, ante a ausência de provas.

- Art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (rés Damariane e Maria Tercina)

A existência material do crime de tráfico ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 13/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), dos laudos toxicológicos (fls. 29/31 e fls. 136/139), do relatório final (fls. 104/105), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto à autoria, a condenação das rés é medida consequencial da prova existente nos autos.

Não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção dos agentes penitenciários em prejudicar as rés. Pelo contrário, o relato dos servidores públicos guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos agentes na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presentes os réus e seus defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestarem, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa -

Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas -

Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ -

Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12,

"caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido.

Estabelecida tal premissa, saliento que, Damariane, em solo policial, confessou que havia repassado a vasilha da marmita, para facilitar a entrada da droga no presídio. afirmou também que a corré sabia dos entorpecentes, porquanto estavam atendendo aos pedidos do marido e do neto, respectivamente, o que demonstra sua participação material para a prática do delito, ainda que não tenha sido ela quem estivesse na posse da marmita, mas sim a corré.

Em seu interrogatório em juízo, entretanto, apresentou versão pouco verossímil, alegando que apenas emprestou uma vasilha vazia à corré, sem saber da sua intenção de entrar com drogas no estabelecimento.

Outrossim, é importante atentar-se para o fato de que as testemunhas que encontraram a droga na marmita narraram com riqueza de detalhes como se deu a apreensão da droga.

Ernesto Rodolfo Guandalin narrou, em solo policial, que "revista, na marmita de Maria, identificaram no seu interior, junto à alimentação que ela estava levando para sua visita, um total de 05 porções de tdh-maconha acondicionadas em invólucros de plástico filme ao qual estava no fundo da respectiva marmita. Relata, que Maria o informou que estava na respectiva unidade para visitar seu neto. Aduz, que teria recebido uma ligação na data anterior (11-01-2020) da indiciada Damariane, sendo orientada a levar a visita uma vasilha de plástico transparente, haja vista que quando chegassem no estacionamento, fora da unidade, iria trocar de vasilha com Damariane. Diante disso, foram em busca da indiciada Damariane e após encontrarem a mesma, logo fizeram busca em seus pertences e encontraram a vasilha da qual Maria diz ser proprietária, inclusive com a etiqueta identificada com seu nome ".

Em juízo, afirmou que "Após encontrarem o volume dentro da vasilha, a ré Maria passou a dizer que não era dela, que havia tido uma troca anterior da vasilha antes de entrarem na unidade. A ré Maria Tercina indicou que a vasilha era da Damariane". Nota-se, assim, o envolvimento das duas corrés.

No mesmo sentido é o depoimento de seu colega, Marcelo Mendonça Camilo, que em juízo afirmou "A princípio, a ré Maria alegou que a sacola não era dela, mas foi indagada, porque todo o procedimento de vistoria é individual e acompanhado pela visitante. Antes, em nenhum momento, mencionou que não era dela a vasilha, apenas após o encontro da substância. Sobre a ré Damariane, recorda-se que também estava na visitação e foi encaminhada para delegacia. A ré Maria Tercina quem indicou que a sacola pertencia à corré Damariane ".

Ora, não seria crível que a corré Maria, ao ser revistada, imputasse uma conduta tão específica à outra corré, indicando que a vasilha era sua, sem que antes não tivesse tido um prévio acordo entre elas.

Vale registrar que a versão da corré Maria se revela, desde o início, isolada nos autos. Isso porque afirma que não tinha ciência da existência da droga dentro da marmita, atendendo apenas a um pedido da corré, embora tenha achado estranho.

Isso porque a prova oral produzida em juízo, somada ao acondicionamento e ocultação do entorpecente (ainda que em quantidade deveras diminuta) e às circunstâncias em que realizado o flagrante, especialmente mediante a constatação de que a substância ilícita seria introduzida em estabelecimento prisional, para consumo alheio (ainda que não se tenha obtido tal intento), deixa evidenciada a traficância denunciada.

Além do mais, o simples fato das rés trazerem consigo as drogas caracteriza a prática pelo réu do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Ou seja, não é necessária prova da comercialização dentro do presídio, tendo em vista que o mero transporte já configura o delito.

O fato da quantidade de drogas ser ínfima também não afasta a tipicidade, uma vez que delitos semelhantes aconteceram diversas vezes nas unidades prisionais pertencentes desta comarca, e o transporte de drogas às penitenciárias sempre é ínfimo, até mesmo para a tentativa de enganar os funcionários. A propósito:

Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada - Básicas reduzidas ao piso - Inexistência de

maior reprovabilidade pela quantidade e natureza dos entorpecentes - As circunstâncias do delito, igualmente, não denotavam necessidade de especial censura - Atenuante da confissão espontânea não caracterizada, já que a acusada negou que tivesse conhecimento sobre as drogas que trazia consigo - Cabimento do tráfico privilegiado em seu redutor máximo - Presença dos requisitos legais - Incidência da majorante decorrente de tráfico cometido nas dependências de estabelecimento prisional - Possível a fixação do regime aberto e a substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0000779-72.2020.8.26.0480; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 14/05/2021; Data de Registro: 14/05/2021).

Ademais, a pequena quantidade, ainda que para transporte e entrega para apenas uma ou duas pessoas, não descaracteriza o delito de tráfico, apenas sendo critério para menor ou maior juízo de censura.

APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/06.

Sentença de procedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório constitucional, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Ausência de dolo ou erro de tipo não verificados. Crime impossível. Inocorrência. Delito de tráfico de drogas que, nas condutas de transportar e trazer consigo entorpecentes, é de atividade formal e de natureza permanente. Precedentes.

Dosimetria. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei nº 11.343/06 bem delineada. Circunstância objetiva suficientemente comprovada nos autos. Reformada a r. sentença para fazer incidir, no grau máximo, o redutor previsto no artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal. Regime aberto que se mostra mais adequado para a espécie, assim como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500447-11.2020.8.26.0616; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021)

Em suma, há indícios em abundância (a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento dos entorpecentes, a tentativa de ocultação das drogas) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas guardadas e mantidas pelos réus tinham por destino o tráfico, e não o consumo próprio.

- Art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas

Todavia, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, as provas dos autos não se revelam suficiente para a condenação.

Concluída a descrição da prova oral coletada ao longo da audiência de instrução, observo que os depoimentos das testemunhas não possuem a certeza de que os detentos, ora corréus, sabiam dos entorpecentes. Os acusados, nas oportunidades em que foram ouvidos, afirmaram que não sabiam das drogas.

A versão das corréis em juízo corroborou a versão dos demais réus, alegando que eles não sabiam das drogas. Ademais, embora uma corré afirme que já haviam entrado com a droga por duas vezes no estabelecimento penitenciário, o que foi negado pelos demais acusados, é certo que, ainda que o fosse verdade, não seria suficiente para sustentar a condenação aqui pretendida.

Destaco que não há um nexo de continuidade temporal relevante entre as condutas, podendo ter sido atos esporádicos, o que afasta a tipicidade da associação para o tráfico.

Em outras palavras, a alegada associação entre os réus não restou provada a contento, pois o máximo que a prova dos autos permite divisar é a coautoria.

Enfatizando a questão, não há qualquer evidência de que os réus associaram-se para a prática do tráfico de drogas, com a necessária habitualidade que o tipo penal requer, inexistindo "prova da estabilidade ou permanência da associação", requisito tido pela doutrina como indispensável e que não se confunde com a eventualidade do tráfico (Nova Lei de Drogas Comentada, Coord. Luiz Flavio Gomes, Editora RT, 2006,

págs. 170/171).

APELAÇÕES CRIMINAIS. 1. PRELIMINAR - Pedido para recorrer em liberdade - Descabimento - Julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade - Manutenção da cautelar de rigor - PRELIMINAR REJEITADA. 2. RECURSO DEFENSIVO - Organização criminosa - Artigo 1º e 2º, da Lei 12.850/2013 - Autoria e materialidade comprovadas - Investigações da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público em que se chegou a autoria do réu - Acusado que integrava o "Primeiro Comando da Capital" - Documentação atestando a "filiação" e "batismo" do réu ao PCC- Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Regime semiaberto - Adequado ao caso concreto, sobretudo diante do quantum da pena - APELO NÃO PROVIDO. 3. RECURSO MINISTERIAL - Associação para o tráfico- Artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 - Decisão que absolveu o acusado quanto a este delito - Recurso ministerial pleiteando a inversão do decisor - Ausência de provas de que, no bojo da organização criminosa, o acusado exercesse com estabilidade e permanência o delito de tráfico de drogas - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0012982-61.2019.8.26.0590; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021

Isto é, em sede processual penal, diante do princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como do princípio do in dubio pro reo - o qual assegura, quando da valoração da prova, que na dúvida, o acusado deve ser absolvido - o grau ou nível de prova exigido (standard probatório) para a prolação de um decreto condenatório é bastante elevado, de modo que este deve ser baseado em provas além de qualquer dúvida razoável. Nesse sentido:

CRIME DO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. (...) 4. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt) e que foi consagrado" (STF, 1ª Turma, AP 580, Rel. Min. Rosa Weber, Data do julgamento: 13/12/2016, Data da publicação: 26/06/2017.). - grifei.

No presente caso, o conjunto probatório é extremamente frágil, por conseguinte, é medida imprescindível, para a consecução da justiça, a absolvição dos réus quanto ao delito de associação.

Por sua vez, em relação ao delito de tráfico imputado às rés Damariane e Maria Tercina, constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do fato, passo a dosar a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06

Damariane Tomaz de Paula

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do insito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: Não há antecedentes (fls. 73/74).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social da ré, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade da ré, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: Cuida-se de crime vago.

I) Natureza e quantidade da droga: Este juízo filia-se ao entendimento de que os

requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos. No caso, a a quantidade das drogas apreendidas, bem como a natureza da droga (maconha), não justificam o aumento da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545); todavia, deixo de a considerar, porquanto a pena já se encontra em seu mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, mantenho a pena em seu mínimo legal.

Da análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, fixo, na segunda fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária de Balbinos, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa..

Por sua vez, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

No caso dos autos, a acusada é primária, em que pese tenha ficado demonstrado o tráfico de drogas, não há provas nos autos de que a ré se dedique a atividades criminosas. Deste modo, reduzo a pena em 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e sua qualidade, considerada de menor potencial ofensivo à saúde, diante das demais drogas existentes, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, mantenho, na terceira fase, a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Maria Tercina da Silva Nogueira

Primeira etapa

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpaabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: Não há antecedentes (fls. 71/72).

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social da ré, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade da ré, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: Cuida-se de crime vago.

I) Natureza e quantidade da droga: Este juízo filia-se ao entendimento de que os requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade) são cumulativos. No caso, a a quantidade das drogas apreendidas, bem como a natureza da droga (maconha) não justificam o aumento da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

Da análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, fixo, na segunda fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



Terceira etapa

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária de Balbinos, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

No caso dos autos, a acusada é primária, em que pese tenha ficado demonstrado o tráfico de drogas, não há provas nos autos de que a ré se dedique a atividades criminosas. Deste modo, reduzo a pena em 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e sua qualidade, considerada de menor potencial ofensivo à saúde, diante das demais drogas existentes, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Assim, mantenho, na terceira fase, a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva, para cada ré, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Aberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Cabível, afinal, as rés são primárias e foram condenadas a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal) e as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição seja suficiente.

Portanto, em atenção ao fato de a pena privativa de liberdade ser superior a 1 (um) ano (artigo 44, § 2º, do Código Penal), aplico, em substituição à pena privativa de liberdade, a pena de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo), a ser revertida à entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal, bem como à prestação de serviços à comunidade também em entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Prejudicado.

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que as rés possuem capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para absolver os réus DAMARIANE TOMAZ DE PAULA, MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA, IRAN FERNANDES RAMOS e DANIEL CEZAR ROCHA, nos termos do art. 386, VII do CPP, quanto ao fato tipificado no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e condenar as rés DAMARIANE TOMAZ DE PAULA e MARIA TERCINA DA SILVA NOGUEIRA por terem praticado fato tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, substituo-a pela pena de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo), a ser revertida à entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal, bem como à prestação de serviços à comunidade também em entidades públicas ou beneficentes, escolhidas pelo juízo da execução penal.

Possibilidade de recorrerem em liberdade, ausentes os pressupostos da prisão

preventiva, tendo em vista o regime inicial aplicado.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, considerando que o sentenciado foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários à advogada nomeada no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Pirajuí, 18 de novembro de 2022.